

1501509-04.2021.8.26.0438

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Victor Alvares Gonçalves

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... flagrante no final de setembro de 2020 por tráfico e associação para o tráfico. Alega que naquela ocasião a droga também foi "forjada", desta vez pelo GAECO. Atualmente está desempregado. É usuário de "cocaína" e "crack" desde os 17 anos" (fls. 14/15).

Em juízo a testemunha PM Bruno Prado de Oliveira disse que já tinha conhecimento sobre o local dos fatos, tendo em vista ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

2ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501509-04.2021.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501509-04.2021.8.26.0438

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSUE ALVES DE OLIVEIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Victor Alvares Gonçalves

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em face de JOSUÉ ALVES DE OLIVEIRA, vulgo Jô, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Segundo consta da denúncia, no dia 26 de agosto de 2021, por volta das 12h00, na Rua Prefeito Doutor Ênio Soliane, n. 1393, Altimari, nesta cidade e comarca de Penápolis, o acusado trazia consigo, para a entrega a consumo de terceiros, 52 porções de crack pesando 13,94 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante (fls. 01/02), tendo sido determinada sua prisão em flagrante (fls. 67/69).

A denúncia foi recebida no dia 14 de outubro de 2021 (fls. 103/104).

Devidamente citado (fls. 131), o réu apresentou defesa prévia alegando ter ocorrido ilegal invasão de domicílio. Afirma que só possuía em sua posse quatro pedras de crack para o seu uso. Tece comentários acerca da ilicitude da denúncia anônima. Requer a absolvição e subsidiariamente desclassificação para o art. 28 da Lei de

Drogas ou aplicação da figura do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Na instrução criminal foi ouvida uma testemunha. Ao final foi interrogado o acusado.

Em alegações orais o Ministério Público requereu a procedência nos termos da denúncia. Já a defesa pugnou pela absolvição do réu ou subsidiariamente pela aplicação do disposto no art. 33, §4º da Lei de Drogas.

É, em síntese, o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente anoto que o caso não partiu de denúncia anônima, mas sim de inteligência prévia dos policiais acerca do envolvimento do réu com o tráfico de drogas, já que já havia sido preso anteriormente pelo mesmo crime.

Por sua vez, não houve ilegal invasão do domicílio, posto que o réu foi abordado em via pública e posteriormente estava em flagrante, tendo inclusive franqueado a entrada, nos termos do depoimento policial.

Assim, não vislumbro ilegalidade na atuação policial no caso concreto.

Indo em frente, a materialidade do crime de tráfico de drogas é positiva, tal como se extrai do auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, do Boletim de Ocorrência de fls. 3/07, do auto de exibição e apreensão de fls. 17/18, do laudo pericial de fls. 86/88, bem como do laudo de constatação provisória de droga de fls. 45/46 e também do exame toxicológico de fls. 89/91, os quais identificaram 52 porções de crack, pesando 13,94 gramas.

A autoria do crime também é certa e restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, pelo BO de fls. 03/07, bem como pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial, como também em juízo.

Na fase administrativa a testemunha PM Juliano Ferreira Lopes disse que “É policial militar e na presente data estava em patrulhamento acompanhado do SD PM Prado quando por volta das 12h00 adentraram na Rua Prefeito Enio Soliane e na altura do numeral 1393 se depararam com o autor Josué, vulgo “Jô”, atravessando a via pública sentido sua residência. Como tinham informações de que Josué estava vendendo drogas, bem como que um primo de Josué de nome Thiago havia sido preso em flagrante no mesmo local com várias porções de “crack”, decidiram por abordá-lo. Feita revista pessoal, foram localizadas no bolso da bermuda jeans do averiguado 52 porções de substância petrificada que não tiveram dúvidas tratar-se de “crack”, embaladas em papel alumínio, umas maiores outras menores, além de uma cédula de R\$ 05,00 (cinco reais). Indagado, Josué confessou ser o proprietário da droga e que ela seria destinada à comercialização; a porção menor seria vendida por R\$ 10,00 e a maior por R\$ 20,00. Ainda, Josué mencionou que não teria nada de ilícito em sua residência, franqueando o acesso da mesma aos policiais. Em buscas pelo local, acompanhados de Josué, encontraram sobre o guarda-roupas no quarto do indiciado um aparelho celular marca Apple modelo iPhone SE e uma balança de precisão em funcionamento. Questionado, Josué afirmou que pegou o celular a troco de drogas, ou seja, como pagamento por entrega de drogas antes realizada, e quanto à balança argumentou que a usava para pesar maconha quando comprava para uso próprio. Josué informou que recebeu o celular de um “nóia” de nome “Maicon”, sem dar maiores detalhes. Diante desse cenário, foi dada voz de prisão em flagrante a Josué e após lidos os seus direitos constitucionais ele foi conduzido ao 01 DP Penápolis com uso de algemas em virtude do receio de fuga. Josué não está machucado e cooperou com o procedimento dos policiais. Josué é conhecido dos meios pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Esclarece o depoente que no começo desta semana soube por intermédio dos “Classificados de Penápolis” na rede social Facebook que uma pessoa havia perdido celular da marca Apple, modelo Iphone SE, nas imediações do 24 Horas, nesta urbe. Através da irmã do dono do celular, Paulo, chegou até este. Paulo compareceu no plantão e prontamente reconheceu o celular recuperado na casa de Josué como sendo seu, sendo-lhe restituído o bem. Sobre a diligência foi elaborado o BO PM 202108261308257.” (fls. 08/09). No mesmo sentido o depoimento da testemunha PM Bruno Prado de Oliveira (fls. 10).

O réu disse que “Que familiares estão cientes de sua prisão em flagrante. Não está machucado e não tem queixas sobre o procedimento dos policiais militares para consigo. Sobre os fatos, deseja se manifestar e nega a prática do crime. Não foi

abordado na rua como disseram os policiais militares. Estava dormindo em seu quarto, endereço supra, e foi acordado pelos policiais. Não sabe de onde surgiu o aparelho celular e a balança de precisão apreendidos. Tinha em depósito, na estante do quarto, apenas 4 porções de "crack" que seriam para consumo pessoal. Não vende drogas. Faz bicos carpindo terreno atualmente e comprou as porções de "crack" com o dinheiro que conseguiu com isso. Pela residência estavam o interrogando e sua esposa Thani Caroline (18) 99618-7910. Thani acompanhou o procedimento dos policiais e pode testemunhar em seu favor. Alega que os policiais mostraram várias porções de "crack" e disseram para o interrogando "segurar a droga", sob pena de prenderem ambos, o interrogando e sua esposa. Questionado, argumenta que o PM Bruno Prado "não gosta" de si, pois moram próximos e ele acredita que estou envolvido com tráfico de drogas. Meu primo Thiago foi preso com drogas recentemente, o que reforçou a animosidade com o citado policial. Informou à autoridade policial quando indagado informalmente que tinha recebido o celular Iphone SE de um "nóia" de nome "Maicon" porque foi orientado pelos policiais militares a assim proceder. Afirma ter sido preso em flagrante no final de setembro de 2020 por tráfico e associação para o tráfico. Alega que naquela ocasião a droga também foi "forjada", desta vez pelo GAECO. Atualmente está desempregado. É usuário de "cocaína" e "crack" desde os 17 anos" (fls. 14/15).

Em juízo a testemunha PM Bruno Prado de Oliveira disse que já tinha conhecimento sobre o local dos fatos, tendo em vista que já realizaram prisão no mesmo local, primo de Josué que mora na casa da frente. Diante das informações que já tinha de tráfico de drogas, viram o réu e resolveram abordar. Encontraram no bolso de seu shorts Jeans 52 porções de crack e cinco reais. O réu informou que seria para venda. Tinha porções de dois tamanhos diferentes. A maior venderia por vinte e a menor por dez reais. Franqueou a entrada na residência. Localizar sobre o guarda-roupa um Iphone e uma balança de precisão funcionando normalmente. Perguntando sobre o celular o réu disse que o aparelho foi trocado por entorpecente pelo indivíduo Maycon. O réu disse que pegou o celular e deu droga para Maycon. No dia dos fatos não tinha mais ninguém na residência. A namorada do réu só compareceu na delegacia.

O réu disse que a acusação não é verdadeira. Estava dentro de casa dormindo. Em posse do depoente tinha quatro porções de crack. É usuário. Seu primo tinha sido preso a pouco tempo na mesma casa. O policial mora na rua da casa do depoente, tem rixa já faz um tempo. O policial Bruno Prado que morava na mesma rua. O policial mora muito próximo, a casa dele tem câmera. Alega ser apenas usuário. Não estava vendendo porque já estava respondendo um processo. Não sabe do celular e nem da balança.

Pois bem.

A quantidade relevante de porções (cinquenta e duas) embaladas para a venda que foram encontradas na posse do réu, revela que a destinação da droga era a comercialização para terceiras pessoas, não podendo ser ignorado que o réu foi abordado na rua, na posse da droga e de dinheiro trocado. Não pode ser ignorado ainda que houve a apreensão de balança de precisão em sua residência, instrumento utilizado para o preparo de droga para a venda.

A versão do réu, de que a situação foi forjada não encontra qualquer respaldo nos autos. Notadamente o réu tem utilizado tal argumentação também em relação à prisão anterior, quando foi abordado pela polícia em Araçatuba, não tendo conseguido justificar a razão pela qual teria disso perseguido por policiais diversos, em municípios diversos deste Estado, o que demonstra a fragilidade de sua versão. Por tal razão, deve prevalecer o depoimento da testemunha PM, que se mostrou íntegro, sem qualquer razão para que duvidasse de sua idoneidade.

Assim, considerando a prova produzida, tenho que a condenação é medida que se impõe, sendo de rigor a condenação do réu pela prática do tráfico de drogas, na modalidade "trazer consigo" e "transportar".

Por outro lado, verifico que o réu é tecnicamente primário, não possuindo maus antecedentes. Também não há comprovação de que se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa. Sendo assim, de rigor a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas. Aplico a minorante pela metade, em razão

do número relevante de porções de droga encontradas com o acusado.

Passo à dosimetria da pena.

Antes de iniciar a fixação da pena-base, esclareço que, nesta primeira fase da dosimetria, a pena sempre partirá do mínimo previsto em lei e, a cada circunstância judicial desfavorável ao réu, a pena mínima será acrescida da fração de 1/10 (um décimo) calculada sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena abstrata prevista para o crime em questão.

A fração a ser aplicada é de 1/10 (um décimo) justamente porque são oito as circunstâncias judiciais a serem valoradas por força do art. 59 do CP, mais duas previstas no art. 42 da Lei de Drogas (natureza e quantidade da droga).

Com isso prestigia-se a proporcionalidade na aplicação das penas, uma vez que se respeita a gravidade do delito, reconhecida pelo legislador, quando da fixação da pena máxima.

Utilizando-se este procedimento, crimes que possuem a mesma pena mínima, mas diferentes penas máximas, justamente por serem de gravidade distinta, serão apenados adequadamente, cada um com sua gravidade e grau de censura já estipulados em lei.

Não é razoável que para crimes de diferente gravidade, a exasperação da pena-base parta do mesmo patamar mínimo, ignorando-se a pena máxima imposta pelo legislador. Sendo assim, como regra, este será o critério utilizado na primeira fase da dosimetria da pena, até para prestigiar o entendimento que vem sendo fixado no âmbito do STJ, conforme se extrai das decisões exaradas no HC 218.249/SP, julgado em 13/09/2016, e no HC 285.490/PE, julgado em 06/10/2016.

Por fim, ressalto que, diante de casos concretos excepcionais, e mediante fundamentação exaustiva, as frações de cálculo poderão ser diminuídas ou aumentadas de forma diversa, para que se possa individualizar adequadamente a pena, até a fim de prestigiar a preponderância da natureza e da quantidade de drogas em relação às demais circunstâncias, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

Isso posto, passo à análise das circunstâncias judiciais.

O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas prevê pena de reclusão de 05 a 15 anos e de 500 a 1500 dias-multa.

Em relação à quantidade da droga apreendida nada a valorar. A natureza da droga merece valoração negativa, já que houve a apreensão de crack, droga de alto poder viciante, extremamente maléfica à saúde humana. A culpabilidade é normal à espécie. A ré não possui maus antecedentes. Quanto à conduta social e a personalidade, inexistem nos autos elementos suficientes para adequada avaliação. O motivo do delito é normal à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. No que pertine às consequências, certo é que não restaram caracterizadas outras consequências além daquelas próprias do tipo penal. Finalmente, não há que se valorar o comportamento da vítima, pois se trata de crime vago, em que a vítima é a sociedade como um todo. Assim, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Ausente qualquer agravante ou atenuante, razão pela qual mantenho a pena-base.

Ausente qualquer causa de aumento de pena. Presente a minorante prevista no art.

33, §4º, da Lei de Drogas, tal como já fundamentado acima, razão pela qual diminuo a pena pela metade, fixando a pena final em 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

Considerando a situação econômica do acusado, o dia-multa será calculado a base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo na data do fato, atualizado pelos índices de correção monetária (§§ 1º e 2º, do art. 49 do CPB).

Para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, adoto o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90, que previa necessariamente o regime inicial fechado para os crimes hediondos.

Ademais, no HC 118.533, recentemente o STF firmou o entendimento de que o tráfico "privilegiado" do art. 33, §4º, da Lei de Drogas não é crime hediondo.

Sendo assim, nos termos do art. 33, §3º e 59, ambos do CP, tendo em vista a pena

aplicada, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime ABERTO (ART. 33, do CP).

Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade

Em face do disposto no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, e de acordo com a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, que aplicou o efeito vinculante à declaração de inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” constante do citado dispositivo legal, substituo, na forma do art. 44, CP, a pena privativa de liberdade aplicada à ré por duas restritivas de direito, a saber: prestação pecuniária no valor de um salário mínimo e prestação de serviços à comunidade, a ser realizada na forma do art. 46, CP – à razão de uma hora por dia de condenação, nos termos a serem definidos pelo juiz da execução.

O réu poderá recorrer em liberdade, vez que ausentes motivos para a segregação cautelar no momento, diante do regime e da substituição por pena restritiva de direitos autorizada.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para o fim CONDENAR o réu JOSUÉ ALVES DE OLIVEIRA, pela prática do delito de tráfico “privilegiado” de drogas (art. 33, caput, c/c art. 33, §4º, ambos da Lei de Drogas), e, por consequência, às penas 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime ABERTO, sendo cada dia-multa arbitrado em 1\30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, a ser prestada em entidade a ser indicada pelo juízo da execução.

O réu poderá recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Disposições finais:

a) Determino a incineração da droga apreendida, caso tal medida ainda não tenha sido tomada pela autoridade policial.

b) Decreto o perdimento do dinheiro e da balança de precisão em favor da União, pois produto do crime e instrumento utilizado para a traficância, tudo nos termos dos arts. 63, §1º, e 64 e da Lei de Drogas.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804, CPP). Concedo a gratuidade da justiça ao réu, diante da situação financeira apresentada, de modo que a exigibilidade das custas fica suspensa (art. 98, §3º, CPC).

Após o trânsito em julgado: a) Oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do art. 15, inciso III, da CF/88; b) Calcule-se a multa, intimando-se para pagamento; c) Expeça-se guia de recolhimento definitiva; d) Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD).

Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Penápolis, 09 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA